

1501043-07.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... espera a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Impossibilidade. Insuficiência de provas a infirmarem a tese defensiva, plenamente compatível com as circunstâncias do art. 28, da Lei 11.343 de 2006. Prisão em flagrante com cerca de 47g de maconha e 0,29g de cocaína (peso líquido). Insuficiência de provas do tráfico de drogas. Inércia da acusação em procurar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501043-07.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501043-07.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 842/21 - 7º Distrito Policial de Santos, 2077962/21 - 7º Distrito Policial de Santos, 2077962 - 07º D.P. SANTOS, 842/21/232 - 07º D.P. SANTOS

SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 28, caput, e 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos.

Consta da denúncia que, desde data incerta até o dia 19 de março de 2021, por volta das 11 horas, na Avenida Presidente Wilson, nº 1935, apto. 1003, em Santos, o denunciado utilizou o apartamento de que tinha a posse para realizar o tráfico ilícito de drogas, sem qualquer tipo de autorização.

No mesmo local e dia, o denunciado guardava, para consumo pessoal, quatro cigarros da erva Cannabis Sativa L. (maconha), droga capaz de causar dependência física e psíquica. Ele agia, também, sem qualquer tipo de autorização.

A denúncia narra que, em circunstâncias não esclarecidas, o denunciado obteve instrumentos e objetos destinados ao cultivo e ao preparo da maconha. Ele providenciou luminárias, lâmpadas, frascos de fertilizante, vasos e lonas

metalizadas, tudo destinado a criar condições propícias ao cultivo da maconha. O denunciado fez isso para comercializar as drogas produzidas, sem autorização legal para tanto.

O denunciado guardou e armazenou esses objetos no apartamento no endereço supracitado, do qual era locatário desde maio de 2020. Ele usou esse imóvel para praticar o tráfico de drogas, através do cultivo da maconha e posterior venda clandestina dessa erva. Depois de cultivar a erva, ele separou parte da droga para seu consumo e confeccionou quatro cigarros. O denunciado também preparou uma porção a granel dessa droga, a deixou em uma caixa de madeira e em uma bandeja no seu apartamento, pois ele pretendia vender essa porção a granel.

Consta da denúncia que, diante da fundada suspeita de que o denunciado armazenava drogas e armas de fogo no endereço, foi autorizada busca e apreensão no apartamento do denunciado.

Então, no dia 19 de março de 2021, Policiais Civis cumpriram a ordem judicial. Isso possibilitou a apreensão dos quatro cigarros de maconha parcialmente consumidos, da porção a granel dessa droga destinada ao comércio ilícito, dos objetos e instrumentos usados para o cultivo da droga, de papéis e "dichavador" destinados à confecção de cigarros, além de agenda com anotações, três celulares e uma máquina própria para receber pagamentos através de cartão.

O denunciado estava no apartamento e foi preso em flagrante. No local também estava presente Ananda de Freitas Costa, que foi ouvida e liberada.

Consta, por fim, que a finalidade de vender a porção a granel de maconha ficou evidenciada pelas seguintes circunstâncias: a quantidade de droga não condizia com o consumo pessoal (aproximadamente 70 gramas); havia objetos e equipamentos destinados ao cultivo e preparo dessa droga em quantidade voltada para o comércio clandestino; e havia anotações das atividades ilícitas do denunciado.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de Ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 18/20).

O acusado foi notificado (fls. 204), e apresentou defesa prévia (fls. 212/230).

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2021 (fls. 240/242).

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 257/260). Laudo dos objetos apreendidos (fls. 290/307). O réu foi citado (fls. 325).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e o interrogatório do réu. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal, pois os fatos narrados na denúncia não foram comprovados. Argumentou que não houve qualquer diligência a apurar a prática do comércio ilícito de entorpecentes pelo réu, sendo que, o que motivou a entrada dos policiais no apartamento dele, foi uma denúncia de que este possuía uma arma de fogo, que não restou comprovada. Aduziu que foram apreendidos apenas dois potes aptos a produzir maconha e, a quantidade de droga apreendida no apartamento e com o acusado, era pequena. Disse que o meio que os policiais disseram que seria utilizado para a produção da droga não combina com a quantidade de entorpecente encontrada na busca e que é incompatível com a mercancia. Por fim, alegou que a prova é fraca para condenar o acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo o caso de condená-lo apenas nas penas do artigo 28, da Lei de Drogas.

A D. Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, para o previsto no artigo 28 da mesma lei. Contudo, argumentou que o delito de posse de entorpecentes para uso próprio é atípico e inconstitucional, sendo de rigor a sua absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A D. Defesa alegou, preliminarmente, a atipicidade e inconstitucionalidade do delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Contudo, razão não assiste à Defesa.

O fato de a matéria estar sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e de haver votos favoráveis à inconstitucionalidade do artigo, não o torna inconstitucional. Anoto que não há que se falar em atipicidade da conduta de porte de drogas para uso próprio, permanecendo, sob a égide do princípio da legalidade, descrita como fato

típico a conduta praticada pelo réu e expressa no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Até porque, sendo a saúde pública o bem jurídico tutelado pela norma, com a posse ou porte do entorpecente, mesmo que para uso próprio, o bem jurídico continua sendo afetado o que torna necessária a sua proteção.

Assim, não há que se falar em conduta atípica ou inconstitucional, com relação ao delito de posse de entorpecentes para consumo próprio.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade apenas do delito de posse de entorpecentes para uso próprio restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), laudo de exame químico - toxicológico (fls. 257/260), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

Isto porque, os indícios da prática do delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, não restaram cabalmente comprovados durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria delitiva do delito do artigo 28, da Lei 11.343/06 é certa.

A testemunha ANANDA DE FREITAS COSTA disse que conheceu o réu pouco tempo antes do ocorrido. Falou que estava na casa do acusado quando três ou quatro policiais bateram na porta e disseram que estavam com um mandado de prisão, contudo, sem dizer o motivo. Disse que eles revistaram a casa e que ficou sentada na sala esperando. Confirmou que foram encontradas lâmpadas de LED, vasos de plantas e alguma quantidade de maconha que o réu disse usar para tratar a ansiedade. Negou que o acusado tenha falado ou que tenha percebido que ele plantava maconha.

A testemunha RICARDO DA SILVEIRA CÁCERES, policial civil, disse que as investigações contra o acusado se iniciaram por conta de uma denúncia de que ele possuía uma arma de fogo que teria sido utilizada para ameaçar uma mulher e o porteiro do prédio. Com o mandado de busca e apreensão, foram à casa do acusado, onde encontraram bastante maconha a granel, saquinhos com maconha prensada e quatro cigarros de maconha parcialmente consumidos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada na residência do acusado. No armário do réu encontraram fertilizantes, lâmpadas, vasos e sementes de maconha para ele plantar, mas não havia nenhuma plantação no momento. O acusado lhe disse que usava maconha para tratar depressão e que usava remédio à base de THC, mas que seria muito caro. Negou que tenha sido feita campana ou outras diligências antes de adentrarem ao local dos fatos. A testemunha contou que acha que o réu conseguiria plantar quatro ou cinco vasos por vez, mas que não sabe quanto ele poderia produzir ao longo do tempo. Quanto à máquina de cartão encontrada, ao ser indagado, o réu disse que era da tabacaria que possuía.

A testemunha FLÁVIO DE SANTANA, policial civil, disse que foram ao local por conta de denúncia de tráfico e de arma de fogo utilizada para ameaçar pessoas no prédio. Na entrada do apartamento já visualizaram uma bandeja com quantidade de entorpecente pronta para consumo, uma quantidade solta para a preparação de cigarros e tabletes prensados. No restante do imóvel encontraram petrechos para o cultivo de maconha, tais como luminária para estufa, sementes e fertilizantes próprios para o cultivo de maconha. A arma de fogo não foi encontrada. Havia uma denúncia de que o réu traficava no prédio e nas proximidades. Negou que tenham feito campana ou investigação na casa do réu antes de representar pelo mandado de busca e apreensão. Disse não saber como a maconha seria cultivada. Foram apreendidas, ainda, uma máquina de cartão, que o acusado disse ser de uma tabacaria, e uma agenda.

A testemunha GERALDO RODRIGUES PRADO JÚNIOR, pai do réu, disse que o acusado faz acompanhamento psiquiátrico desde os oito anos de idade e que, aos quatorze anos, iniciou o uso de entorpecentes. Relatou que o acusado já ficou diversas vezes internado por conta do vício em drogas. Disse que o acusado lhe informou que o uso da maconha o deixava mais estável. Confirmou que o réu lhe disse que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, havia alguns cigarros de maconha na residência para uso próprio. Falou que o acusado não traficava e que mandava dinheiro para ajuda-lo a se sustentar. Sobre a máquina de cartões, disse que era da tabacaria que o acusado tinha em Brasília.

O réu GUILHERME PINHEIRO RODRIGES PRADO, interrogado, disse que os fatos são

falsos. Afirmou que tinha em sua casa maconha o suficiente para passar uma semana e que isso não totalizaria 70 gramas, conforme os policiais afirmaram. Confirmou que os quatro cigarros de maconha parcialmente consumidos eram seus. Quanto à porção a granel encontrada, disse que eram restos imprestáveis da maconha que já havia utilizado para fazer os seus cigarros, e que jogaria as sobras no lixo. Negou a mercancia de entorpecentes e disse que nunca teve arma de fogo. Sobre a máquina de cartão, afirmou que ela nunca foi usada, e quanto à agenda apreendida, que ela possuía informações sobre produtos terapêuticos que comercializava. Apesar de possuir petrechos para plantar maconha, nunca chegou a plantar e nem tinha terra em casa para fazê-lo, pois estava aguardando autorização da Anvisa para tanto.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Conforme consta dos testemunhos dos policiais civis ouvidos em juízo, não ficou muito claro o motivo que ensejou o início das investigações.

O que é possível concluir dos seus depoimentos e do pedido de busca e apreensão juntado em apenso, é que houve o registro de ocorrências contra o réu sobre a prática do crime de ameaça, em que ele fazia menção de possuir uma arma de fogo. A única menção a drogas nos boletins de ocorrências registrados, diz a respeito de uma denúncia anônima que o réu disse que havia sido feita contra ele.

Deferido o mandado de busca e apreensão para procurar arma de fogo na residência do acusado, os policiais se depararam com os entorpecentes e os utensílios apreendidos.

Os policiais disseram que não foi feita nenhuma campana ou diligências complementares para se verificar tanto a existência da arma de fogo quanto da prática do delito de fabricar ou plantar maconha para a finalidade de venda ilícita no imóvel em que o acusado residia.

Os apetrechos supostamente utilizados para o plantio foram apreendidos, contudo, o laudo pericial não foi conclusivo acerca da maneira que seriam utilizados, de sua potencialidade para a produção de entorpecentes, qual seria a capacidade de produção e, finalmente, havendo possibilidade de se plantar maconha, se a produção seria suficiente para o comércio ilícito de entorpecentes.

Conforme o acusado destacou, não havia nem mesmo terra no local que possibilitasse a plantação da droga.

Não há qualquer laudo da máquina de cartões apreendida para que se pudesse saber se foi usada, em qual frequência, ou alguma outra informação que se pudesse inferir que seria utilizada para receber pagamentos referentes à mercancia de drogas.

Ainda, não consta laudo no celular do acusado e nem de suas anotações que pudesse ligá-lo de forma firme à plantação e venda de maconha. De outra banda, é bastante razoável a versão apresentada pelo acusado a justificar as anotações, pois faz sentido que sejam referentes a produtos terapêuticos ou a terapias.

A testemunha que estava no local dos fatos, Ananda, confirmou que o réu disse ser usuário de maconha para tratamento de ansiedade e de depressão. Ela disse, também, que, apesar de terem sido encontrados lâmpadas de LED e vasos, não havia qualquer plantação do entorpecente no local.

O réu, por sua vez, não nega que seja usuário de drogas. Pelo contrário, ele afirma que é usuário há vários anos com o intuito de tratar questões psiquiátricas.

A sua testemunha de defesa, o seu pai, confirma que o acusado utiliza, desde a adolescência, entorpecentes, e que já passou por diversas clínicas de recuperação. Portanto, não há nos autos, nada que comprove que o réu utilizava a residência que morava para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo crível a versão de que ele é dependente químico. Ainda mais por ser embasada pelo laudo produzido no incidente de dependência toxicológica, que conclui pela dependência de maconha (fls. 55/58 - apenso 0005645-37.2021.8.26.0562).

Assim, com a investigação rasa feita pela polícia, não há elementos suficientes nos autos que possam ensejar a responsabilização penal do acusado pelo crime previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei de Drogas, não se podendo condenar criminalmente uma pessoa por mera previsibilidade. Para tanto, exige-se prova segura, o que nos autos não possui. Sendo de rigor a sua absolvição por este crime. Já o delito de posse de entorpecente para uso próprio restou cabalmente comprovado e confessado pelo acusado.

Com relação à quantidade de substância entorpecente apreendida, não se pode dizer ser incompatível àquela geralmente encontrada para consumo pessoal, ainda mais quando se leva em consideração a constância do uso da droga pelo réu. Da mesma forma, a localização de uma única espécie de substância entorpecente aponta no mesmo sentido, ou seja, de que aquela se destinava ao consumo pessoal. Outrossim, foram apreendidos no local vários apetrechos para uso do entorpecente, o que dá mais peso à versão apresentada pelo acusado de que possuía maconha para consumo pessoal.

Ademais, não demonstrando o intuito de venda ou entrega do entorpecente a terceiro, é de se concluir pela hipótese mais benéfica ao acusado, qual seja, de que a droga estava no local para consumo próprio.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal. Ação penal julgada procedente em parte, condenando o réu à pena de advertência. Recurso ministerial com vistas à condenação por tráfico, nos moldes da denúncia. Insurgência que não procede. Não configuração do intuito de entregar as substâncias ao consumo de terceiros. Quadro probatório inseguro. Sentença mantida. Não provimento da apelação." (TJSP; Apelação Criminal 0004546-53.2017.8.26.0568; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo." (TJSP; Apelação Criminal 0001018-89.2017.8.26.0542; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, a convergir para a figura típica do caput do dispositivo. Desclassificação operada. Pena de prestação de serviços à comunidade. Apelo provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 0000002-42.2019.8.26.0571; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

"POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo ministerial que espera a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Impossibilidade. Insuficiência de provas a infirmarem a tese defensiva, plenamente compatível com as circunstâncias do art. 28, da Lei 11.343 de 2006. Prisão em flagrante com cerca de 47g de maconha e 0,29g de cocaína (peso líquido). Insuficiência de provas do tráfico de drogas. Inércia da acusação em procurar a confirmação de indício mencionado por uma das testemunhas policiais. Dinâmica dos fatos que não permite certeza acerca da traficância. Desclassificação confirmada. Apelo improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500141-22.2018.8.26.0128; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

De rigor, por conseguinte, a condenação do réu pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso.

Passo à dosimetria da pena.

Observando a quantidade de droga apreendida e considerando o tempo que o réu ficou preso cautelarmente, vinte e dois dias, nos termos do inciso I, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, aplico-lhe a pena de advertência quanto aos efeitos da droga. Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, o que faço para:

CONDENAR o acusado GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO, qualificado nos autos, à

pena de advertência, por infração ao artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06;
ABSOLVER o acusado GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO, qualificado nos autos, do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo ao réu o direito de interpor e aguardar eventual recurso em liberdade.
Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.
Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.
Condene o réu ao pagamento das custas processuais.
P.I.C.

Santos, 29 de abril de 2022.
Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA